

09 Anfängerfehler Katalog mit Partner Rotstift

Lehrmaterial für den ersten Big-Law-Sommer. Auf der linken Seite typische Anfängerformulierungen aus echten Associate-Drafts. Auf der rechten Seite die Korrektur, wie Dr. Adelheid von Westarp sie schreiben würde, mit kurzem Grund.

Lesehinweis: Wer dieselbe Stelle dreimal so verändert bekommt, muss sich die zugrunde liegende Begriffsstruktur noch einmal anschauen, nicht nur die Formulierung.

1. Fehlerklasse A: Begriffsverwechslung

(a) A1 Cap Table ist die Gesellschafterliste

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Der aktuelle Cap Table ist die zum Handelsregister eingereichte Gesellschafterliste vom 15.04.2024.“	„Die Gesellschafterliste (Paragraf 40 GmbHG) bildet die formell eingetragenen Gesellschafter ab. Der Cap Table ist ein internes Bewertungsinstrument, das zusätzlich ESOP-Reservierung, ausstehende Wandeldarlehen und VSOP-Anteile auf voll verwässerter Basis berücksichtigt. Beide Darstellungen sind nicht identisch und sollten in jedem Memo getrennt geführt werden.“
Warum: Wer beide Dokumente gleichsetzt, verliert in jeder Series A den Überblick über Pool-Shuffle, Convertibles und VSOP-Wirkung.	

(b) A2 Vesting ist ein Anwartschaftsrecht

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Gründer haben ein Anwartschaftsrecht auf ihre Anteile, das nach Maßgabe des Vesting-Schedules erstarkt.“	„Die Gründer sind bereits voll an ihren Geschäftsanteilen berechtigt. Die Vesting-Regelung wirkt schuldrechtlich über eine bedingte Call-Option der Gesellschaft auf die Unvested Shares zugunsten der Gesellschaft. Der Begriff Anwartschaftsrecht ist sachenrechtlich besetzt und sollte hier nicht verwendet werden.“
Warum: „Anwartschaftsrecht“ hat im deutschen Recht eine eigenständige sachenrechtliche Bedeutung (etwa bei Eigentumsvorbehalt oder Auflassungsvormerkung) und wird in Klausuren wie in Verträgen sofort missverstanden.	

(c) A3 Liquidation Preference greift nur in der Insolvenz

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Liquidation Preference des Investors bedeutet, dass dieser bei einer Insolvenz seine Einlage zuerst zurückerhält.“	„Die Liquidation Preference ist ein Erlösvorzug, der bei jedem im SHA definierten Liquidation Event greift, insbesondere bei einem Share Deal, einem Asset Deal oder einem Merger. Sie wirkt gerade auch beim erfolgreichen Verkauf unterhalb eines bestimmten Erlösniveaus.“
Warum: Wer Liquidation Preference mit Insolvenz übersetzt, übersieht die wirtschaftlich entscheidenden Verteilungseffekte beim normalen Exit.	

(d) A4 Anti-Dilution ist ein Bezugsrecht

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Anti-Dilution-Klausel sichert dem Investor ein gesetzliches Bezugsrecht in künftigen Finanzierungsrunden.“	„Die Anti-Dilution-Klausel passt das Wandlungsverhältnis (Conversion Ratio) der Vorzugsanteile in einer Down Round an. Sie wirkt rückwirkend auf den wirtschaftlichen Wert der bestehenden Anteile. Das Bezugsrecht ist eine davon zu trennende Frage der Beteiligung an der neuen Kapitalerhöhung und wird typischerweise in einer Pre-Emption-Klausel oder Pro-Rata-Right-Klausel geregelt.“
Warum: Anti-Dilution und Bezugsrecht sind komplementär, aber rechtlich unterschiedliche Mechanismen.	

2. Fehlerklasse B: Englisch eindeutschen ohne Funktion zu prüfen**(a) B1 Reps and Warranties gleich Gewährleistung**

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Verkäufer übernehmen die handelsübliche Gewährleistung gemäß Paragraph 434 BGB für die erworbenen Anteile.“	„Die Verkäufer geben selbständige vertragliche Garantien (Reps and Warranties) im Sinne eines selbständigen Garantieversprechens. Die gesetzliche Sachmangelhaftung nach Paragraph 434 BGB wird ausgeschlossen; das Haftungsregime ergibt sich abschließend aus Abschnitt ... dieses Vertrages.“
Warum: „Gewährleistung“ weckt gesetzliche Rechtsfolgen, die im SPA fast immer ausgeschlossen oder anders ausgestaltet werden.	

(b) B2 Indemnity gleich Schadensersatz

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Der Verkäufer verpflichtet sich zum Schadensersatz für Steuernachforderungen, die vor dem Closing entstehen.“	„Der Verkäufer verpflichtet sich zur Freistellung (Indemnity) gegen jegliche Steuernachforderungen, die vor dem Closing entstanden sind, einschließlich der Übernahme der Verteidigungskosten und der Erfüllung der Forderung. Verfahrensregeln zur Anzeige (Notice), zur Verteidigungsführung (Conduct of Defense) und zum Cap sind in Abschnitt ... geregelt.“
Warum: Freistellung und Schadensersatz haben unterschiedliche Inhalte und Verfahren.	

(c) B3 Investor Director Approval gleich Beiratsbeschluss

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Investor Director Approval ist als Beiratsbeschluss umzusetzen.“	„Der Begriff Investor Director Approval verlangt eine doppelte Umsetzung. Erstens auf Ebene der Beiratsgeschäftsordnung, sofern der Beirat Entscheidungskompetenz erhalten soll. Zweitens auf Ebene des Gesellschafter-Zustimmungsvorbehalts in Satzung oder SHA, sofern die Materie einem Veto-Vorbehalt des Investors unterliegen soll. Eine schlichte Umsetzung als Beiratsbeschluss greift zu kurz, weil der Beirat einer GmbH ohne Satzungs- oder Geschäftsordnungsgrundlage nicht entscheidungsbefugt ist.“

Associate Draft	Partner-Korrektur
Warum: GmbH-Beirat ohne Kompetenzgrundlage ist beratend. Investor Director Approval muss in das deutsche Organgefüge übersetzt werden.	

(d) B4 Drag-Along als Vorkaufsrecht

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Drag-Along-Klausel räumt den Investoren ein Vorkaufsrecht ein.“	„Die Drag-Along-Klausel verpflichtet die Minderheitsgesellschafter, ihre Anteile zu denselben Konditionen wie die ziehende Mehrheit an einen Drittkäufer zu veräußern, sofern die im SHA festgelegten Schwellen erfüllt sind. Es handelt sich um eine Mitverkaufsverpflichtung, nicht um ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal).“
Warum: Vorkaufsrecht regelt die Reihenfolge bei einem geplanten Verkauf, Drag-Along eine Verkaufsverpflichtung an einen identifizierten Dritten.	

3. Fehlerklasse C: GmbH-Recht und Notar übersehen**(a) C1 SHA-Klausel reicht für Vinkulierung**

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Anteilsübertragung bedarf der Zustimmung der Series-A-Majority gemäß SHA.“	„Eine Vinkulierung muss in der Satzung verankert sein, um gegenüber jedem Erwerber zu wirken (Paragraf 15 Absatz 5 GmbHG). Eine rein schuldrechtliche SHA-Klausel bindet nur die Vertragsparteien. Sofern der Investor eine wirksame Vinkulierung gegenüber Dritten wünscht, ist Paragraf 6 der Satzung anzupassen und die Schwellen mit dem SHA zu harmonisieren.“
Warum: SHA-Klauseln ohne Satzungsumsetzung sind gegenüber Erwerbern in der Regel nicht durchsetzbar.	

(b) C2 Notarpflicht nur bei Anteilsübertragung

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Beurkundungspflichtig sind nur Anteilsübertragungen nach Paragraf 15 Absatz 3 GmbHG.“	„Beurkundungspflichtig sind neben Anteilsübertragungen unter anderem die Errichtung der Gesellschaft, jede Satzungsänderung einschließlich Kapitalerhöhung (Paragrafen 2, 53 GmbHG), schuldrechtliche Verpflichtungen zur Anteilsübertragung (Paragraf 15 Absatz 4 GmbHG) und Verträge, die als Einheit mit dem beurkundungspflichtigen Geschäft anzusehen sind. Im SHA enthaltene Übertragungsverpflichtungen können selbst beurkundungsbedürftig sein, wenn sie konkret genug sind, oder mitbeurkundungspflichtig nach der Einheitsdoktrin.“
Warum: Versteckte Beurkundungsbedürftigkeit ist eine der häufigsten Falltüren in der M+A-Praxis.	

(c) C3 Wandeldarlehen kann formfrei sein

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Das Wandeldarlehen mit Tante Ermelind Capital UG ist formfrei wirksam, da nur ein schuldrechtlicher Anspruch auf Wandlung in Anteile begründet wird.“	„Soweit das Wandeldarlehen eine Verpflichtung zur Übertragung von Geschäftsanteilen oder zur Übernahme neuer Geschäftsanteile in einer Kapitalerhöhung enthält, ist die Beurkundungsbedürftigkeit nach Paragraph 15 Absatz 4 GmbHG (Verpflichtung zur Übertragung) bzw. Paragraph 55 GmbHG (Übernahmeerklärung bei Kapitalerhöhung) zu prüfen. Eine schlichte schuldrechtliche Wandlungsoption kann beurkundungspflichtig sein, sofern sie hinreichend konkretisiert ist. Vor Closing ist zu prüfen, ob das vorhandene DocuSign-Dokument formgerecht ist; gegebenenfalls ist eine notarielle Bestätigung oder Neufassung erforderlich.“
Warum: Convertibles ohne formgerechte Dokumentation sind ein Closing-Showstopper.	

(d) C4 Englischer Text reicht beim Notar

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Grundlage der englischen Investment-Agreement-Fassung die Kapitalerhöhung.“	„Notariell zu beurkundende Erklärungen sind nach Paragraph 5 BeurkG grundsätzlich in deutscher Sprache abzugeben. Eine Niederschrift in einer fremden Sprache ist nur unter den Voraussetzungen von Paragraph 5 Absatz 2 BeurkG zulässig, insbesondere bei genügender Sprachbeherrschung und mit anschließender beglaubigter Übersetzung oder dem Verzicht der Beteiligten. In der Praxis werden Satzung, Übernahmeerklärung, Anteilsabtretung und Liste neuer Gesellschafter regelmäßig in deutscher Sprache beurkundet, begleitet von einer englischen Übersetzung für die Mandantin. Investment Agreement und SHA bleiben in englischer Sprache, ohne dass dies die Beurkundungspflicht in deutscher Sprache aufhebt.“
Warum: Anwendbares Recht, Vertragssprache und Beurkundungssprache sind drei getrennte Ebenen.	

4. Fehlerklasse D: Fully diluted und Pool-Mathematik**(a) D1 Pool wird vom Investor mitgetragen**

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Die Erhöhung des Option Pools auf 12 Prozent verwässert alle Gesellschafter gleichmäßig.“	„Bei einer Pre-Money-Pool-Konstruktion wird der zusätzliche Option-Pool aus dem Pre-Money-Anteil herausgerechnet. Wirtschaftlich verwässert dieser Mechanismus die Bestandsgesellschafter, nicht den Investor. Eine Post-Money-Pool-Konstruktion verteilt die Verwässerung auf alle Beteiligten. Vor Term-Sheet-Akzeptanz ist mit konkreten Zahlen vorzurechnen, welcher Mechanismus angewendet wird.“
Warum: Wer den Pool-Shuffle nicht erkennt, verliert wirtschaftlich.	

(b) D2 Wandeldarlehen ist im fully diluted egal

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Das Wandeldarlehen Tante Ermelind ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht Teil des fully diluted Cap Table, da die Wandlung noch nicht erfolgt ist.“	„Wandeldarlehen sind im fully diluted Cap Table mit ihrer Wandlungsformel und einem definierten Wandlungsszenario abzubilden. Discount und Valuation Cap führen typischerweise zu unterschiedlichen Wandlungsergebnissen je nach Pre-Money der Folgerunde. Vor Term Sheet ist ein Wandlungsszenario zur Series A durchzurechnen und Bestandteil der Verhandlung.“
Warum: Convertibles, die im fully diluted Cap Table fehlen, sind in der Praxis der Hauptgrund für Streit am Verhandlungstisch.	

(c) D3 VSOP ist Cap Table neutral

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Das VSOP-Programm ist als virtuelles Programm Cap-Table-neutral und muss in der fully-diluted-Berechnung nicht berücksichtigt werden.“	„Virtuelle Beteiligungen führen nicht zu ausgegebenen Geschäftsanteilen, wirken aber wirtschaftlich auf den Exit-Erlös. Sie werden im Cap Table als gesonderter Block ausgewiesen oder als Equivalent in den fully-diluted Berechnungen miteinbezogen, je nach Vertragssprache. Im Term Sheet ist zu klären, ob VSOP in die fully-diluted-Berechnung eingerechnet wird; das wirkt auf den Pre-Money-Bewertungsanker.“
Warum: VSOP, das in der Cap-Table-Mathematik fehlt, taucht spätestens beim Exit-Waterfall wieder auf.	

5. Fehlerklasse E: Prozesshaltung**(a) E1 Term Sheet ist verbindlich oder nicht**

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Das Term Sheet ist im Wesentlichen unverbindlich, daher nur eine Verhandlungsskizze.“	„Das Term Sheet ist im Hauptteil unverbindlich, mit Ausnahme der ausdrücklich als bindend gekennzeichneten Klauseln (Confidentiality, Exclusivity, Costs, Governing Law, Dispute Resolution). Diese verbindlichen Inhalte sind genauso ernst zu nehmen wie ein abschließender Vertrag, insbesondere die Exklusivität und die Kostenregelung. Verstöße können Schadensersatzansprüche begründen.“
Warum: Wer Exklusivitäts- und Kostenklauseln im Term Sheet unterschätzt, erlebt am Closing eine teure Überraschung.	

(b) E2 Senior-Review-Gate optional

Associate Draft	Partner-Korrektur
„Vor Versand an Investor Counsel würde ich vorschlagen, das interne Briefing freizugeben.“	„Vor Versand an Investor Counsel sind die folgenden Senior-Review-Gates verpflichtend: (1) Cap-Table-Rechenmodell durch Counsel verifiziert; (2) Term-Sheet-Übersetzung der Schlüsselbegriffe Partner-freigegeben; (3) Beurkundungspflichten und Notarslot mit Notariat geklärt; (4) steuerliche Folgen mit Steuerberatung abgestimmt; (5) Antwort-

Associate Draft	Partner-Korrektur
	ten auf Mandantenfragen im Originalwortlaut der Mandantin verfasst. Erst danach Versand."
Warum: Schreibstil signalisiert die Erwartung an die eigene Sorgfalt. Konjunktive ersetzen keine Gates.	

6. Tutoriumseinheit für die Praxisrunde

In der wöchentlichen Praxisrunde der Frankfurter Corporate-Praxis werden zwei der oben gelisteten Fehlerklassen anhand von echten Anonymisierungen durchgegangen. Wer die Aufgabe hat, beim nächsten Termin Lead zu sein, bringt zwei eigene Drafts aus der vergangenen Woche mit, in denen er oder sie eine der Fehlerklassen vermieden hat, und einen Draft, an dem er oder sie noch arbeitet.